

1501022-29.2021.8.26.0472

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... apontando seu envolvimento com o tráfico demonstram, com segurança, que o denunciado trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de tráfico."

A pessoa imputada foi presa em flagrante (fls. 01/02).

Em decisão de fls. 49/53 o flagrante foi relaxado.

O representante do Ministério Público ofereceu a citada denúncia às fls. 118/120.

A denúncia não foi recebida por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, . - Centro

CEP: 13660-017 - Porto Ferreira - SP

Telefone: (19) 3581-2201 - E-mail: portoferr2@tjsp.jus.br

1501022-29.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501022-29.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WANDERSON ANTONIO GONCALVES

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de WANDERSON ANTONIO GONCALVES, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33 da Lei 11.343/06 afirmando que em 19 de agosto de 2021, por volta de 08h, na rodovia SP 330, próximo à empresa Vidro Porto, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, trazia consigo 42 microtubos e 01 porção a granel de "cocaína", com peso líquido total de 15,99 gramas e 02 porções de "maconha" com peso líquido de 3,32 gramas.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "guardas civis municipais passavam pelo Jardim Anésia, local com grande incidência do tráfico de drogas, quando foram solicitados por um popular que não quis se identificar, tendo este noticiado aos agentes públicos que um indivíduo de cor parda, trajando camisa social de cor azul, estava se deslocando a pé daquele bairro para o centro da cidade levando consigo certa quantidade de entorpecentes. Diante da notícia de flagrante delito em andamento e a fim de apurar a veracidade das informações recebidas, os agentes se descolaram ao centro da cidade, no trajeto, avistaram um

indivíduo com as características informadas já defronte à empresa Vidro Porto, ainda na Rodovia Anhanguera. Realizada a abordagem e busca pessoal, os agentes localizaram em poder do increpado uma meia contendo as drogas acima mencionadas, a saber, 42 eppendorfs e 01 porção a granel de "cocaína", 02 porções de "maconha". Conduzido à Delegacia de Polícia e, formalmente interrogado pela d. Autoridade Policial, o denunciado afirmou "... que nesta data comprou 42 eppendorfs com cocaína e duas unidades de maconha, no Bairro Jardim Anézia, não desejando informar o local; que, comprou a droga pela quantia de R\$ 300,00 reais e iria levar em festa familiar na cidade de Tambaú, para o uso de todos pelo local" (fls. 05 e 99). De se destacar que, no dia 13/09/2021, a companheira do denunciado foi ouvida na Delegacia de Polícia e declarou que "... Wanderson é usuário de drogas e ele também vende os entorpecentes ... Há cerca de vinte dias Wanderson foi preso pelo crime de tráfico de drogas, mas ele foi solto no mesmo dia ... Por fim, a declarante deseja deixar consignado que Wanderson abandonou o serviço de lapidador para vender drogas porque ele considera que ganha mais dinheiro ..." (cf. doc. Anexo extraído dos autos nº 1501081-17.2021.8.26.0472 - 1ª Vara), outro indicativo de seu envolvimento com o vil comércio. Assim, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, corroborando as informações previamente recebidas pela guarda civil municipal, a versão do próprio denunciado, de que as drogas se destinariam, também, a terceiros e as declarações de sua companheira apontando seu envolvimento com o tráfico demonstram, com segurança, que o denunciado trazia consigo os entorpecentes com a finalidade de tráfico."

A pessoa imputada foi presa em flagrante (fls. 01/02).

Em decisão de fls. 49/53 o flagrante foi relaxado.

O representante do Ministério Público ofereceu a citada denúncia às fls. 118/120.

A denúncia não foi recebida por decisão de fls. 122/133 a qual considerou que as provas elencadas pela acusação tinham origem ilícita.

O representante Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito às fls. 142/147.

O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial em acórdão de fls. 184/191 determinando o recebimento da denúncia.

Foi apresentada defesa prévia às fls. 269/273, após a citação de fls. 258/259.

Foi realizada audiência de instrução com apresentação de alegações finais pelas partes.

Quanto ao estado de liberdade, o Tribunal de Justiça determinou, por acórdão de fls. 184/191 dos autos apensos 0001271-54.2021.8.26.0472, a prisão da pessoa imputada.

O mandado foi expedido às fls. 258/259 dos presentes autos.

Há notícia do cumprimento às fls. 265.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Com a devida vênia ao respeitável acórdão, transcorrida a instrução, é o caso de concluir pela absolvição em razão da ilicitude da prova colhida.

A decisão que relaxou o flagrante ficou assim fundamentada:

Está-se a analisar a legalidade da prisão e o estado de liberdade da pessoa de WANDERSON ANTONIO GONCALVES.

A Constituição garante a intimidade de todos, bem como o direito à livre locomoção (incisos X e XV do art. 5º da Constituição).

As forças policiais tem o dever constitucional de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144).

Para tanto, em razão do princípio da legalidade (art. 37 da Constituição), devem atuar nos exatos limites estabelecidos pela lei (desde que esta não viole as normas constitucionais).

Os policiais militares, responsáveis pelo policiamento ostensivo (§5º do art. 144 da Constituição), podem mitigar a intimidade e a liberdade de locomoção dos cidadãos sempre que estiverem diante de "fundadas suspeitas" (§2º do art. 240 do Código de Processo Penal).

No caso, os policiais militares apontaram como justificativa para a busca pessoal uma denúncia anônima.

No entanto, o STJ, tribunal responsável pela uniformização da aplicação do direito processual penal no Brasil (art. 22, inciso I, c.c. art. 105, inciso III, ambos da Constituição), tem entendido que denúncias anônimas e apresentação de nervosismo por parte do investigado não constituem "fundadas suspeitas" a ponto de legitimar a diligência invasiva.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal.

2. Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal.

3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.

HC 625819/SC, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021.

Obviamente, o encontro posterior do bem de origem ilícita não torna válida a diligência.

É sempre bom lembrar a decisão do STF por ocasião do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, publicado em 10/05/2016) quando, em matéria absolutamente análoga (busca domiciliar sem mandado judicial), decidiu que não será a constatação de situação de flagrância, posterior à diligência, que justificará a medida, devendo os agentes estatais demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (em nosso caso, "suspeitas") para a medida.

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo.

3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5º, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2º, e Pacto Internacional sobre

Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

Não diverge o STJ (sem grifos no original).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio.

2. Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

3. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no "nervosismo" apresentado pelo acusado. Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal.

4. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

HC 659689/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021.

Como o art. 312 do Código de Processo Penal exige como requisito da prisão preventiva a prova da existência do crime e tendo a prova da suposta infração penal sido obtida por meio ilícito, o que não é admitido conforme clara determinação constitucional (inciso LVI do art. 5º), impossível a imposição da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto, nos termos do inciso LXV da Constituição e do inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, declaro o flagrante ilegal, determinando o imediato relaxamento da prisão.

Expeça-se o respectivo alvará de soltura clausulado.

Consta da decisão que não recebeu a denúncia:

Lendo a peça ministerial, com a devida vênua ao representante do Ministério Público, dois pontos ficaram por ser ditos.

(1) Não se trata de mera denúncia popular. Trata-se de DENÚNCIA ANÔNIMA. Os guardas municipais justificaram a abordagem em razão de denúncia anônima. Tal argumento não tem sido aceito pela jurisprudência. Isso pode ser remontado ao item 4 do Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603616, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, publicado em 10/05/2016) (aplicado por analogia):

(...) a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias (...)

Ou seja, para que os pressupostos da busca domiciliar e pessoal sem mandados judiciais seja válida, é necessário que os motivos alegados sejam "sindicáveis", isto é, passíveis de controle por parte da defesa. Ora, qual defesa efetivamente cabe contra argumentos tais como "denúncia anônima" ou "nervosismo"?

Não se trata de colocar sob dúvida a palavra do policial (guarda municipal, no caso), como a posição mais açodada leva a concluir. Trata-se tão somente de estabelecer um padrão pelo qual seja possível o controle da atividade policial, impedindo que tão nobre e essencial atividade seja confundida com o arbítrio. Aliás, é como o STJ (tribunal responsável pela uniformização do direito processual penal no país conforme art. 105, inciso III, c.c. art. 22, inciso I, ambos da Constituição) recentemente se manifestou (grifos nossos):

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA PARA INTERIOR DA RESIDÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar pessoal executadas por autoridade policial sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, com base apenas em denúncia anônima (art. 240, § 2º- CPP), bem como a prova derivada da busca pessoal.

2. Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais (nervosismo ante a presença da autoridade policial e ingresso no interior do imóvel), sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP.

3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão da droga e, consequentemente, trancar a ação penal n. 5014975-62.2021.8.24.0033 (art. 386, II - CPP), determinando a restituição da liberdade dos pacientes, se por outro motivo não estiverem presos.

HC 687342/SC, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021.

(2) Os guardas municipais não encontraram o agente em flagrante delito. Dando o devido respeito ao texto constitucional, as guardas municipais tem por função proteção de bens, serviços e instalações dos municípios (§8º do art. 144). Seus agentes tem, enquanto "qualquer do povo", a faculdade de dar voz de prisão quando encontrarem alguém em flagrante delito (art. 301 do Código de Processo Penal).

Mas não possuem qualquer atribuição para proceder a diligências invasivas que levem ao desvendamento da infração.

O art. 37 da Constituição impõe a toda a administração o respeito ao princípio da legalidade, segundo o qual a administração só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Aliás, para as guardas municipais esta exigência está expressa na parte final do §8º do art. 144.

Eis o que dispõe a lei complementar local de n.º 179, de 28 de novembro de 2017,

com redação praticamente idêntica ao texto da Lei (federal) 13.022/2014:

CAPÍTULO II

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

Art. 3º São princípios, básicos, da Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira aqueles elencados na Lei Federal nº 13.022/14.

I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas;

II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas;

III - patrulhamento preventivo;

IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e

V - uso progressivo da força.

VI - compromisso com os princípios que regem a administração pública e respeito ao Estado Democrático de Direito.

Art. 4º É competência geral da Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira a proteção dos bens, serviços, logradouros públicos e instalações municipais e proteção às pessoas em todo Município, nos termos do § 8º, do art. 144, da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.

Art. 5º São competências, específicas, da Guarda Civil Municipal; respeitadas as competências dos órgãos Federais e Estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;

VI - exercer nas vias e logradouros municipais a fiscalização de trânsito, lavrar autuações e aplicar medidas administrativas, pelas infrações de circulação, parada e estacionamento, nos termos do art. 24 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro);

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança da comunidade;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, por meio da celebração de convênios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme Plano Diretor Municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários;

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Civil Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de Segurança Pública da União e do Estado, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV, deste artigo; diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Civil Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

Art. 6º É considerado serviço próprio do Guarda Civil Municipal, para todos os efeitos legais, inclusive a arregimentação, o exercício em cargo ou funções de natureza de segurança, bem como os de ensino e aprendizagem nos assuntos da área de sua atuação.

Art. 7º A Guarda Civil Municipal de Porto Ferreira será custeada com recursos próprios consignados na Lei Orçamentária Anual, além de subvenções, donativos e contribuições.

Ora, partindo do princípio da legalidade, o máximo que podem os guardas municipais locais é "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário". Não há qualquer autorização para diante de suspeitas de flagrantes proceder a medidas invasivas.

É preciso aqui fazer um alerta contra o argumento fácil e tentador de "quem pode o mais (prender), pode o menos (busca pessoal)". Como a decisão com base em valores abstratos exige a ponderação das consequências práticas (art. 20 do Decreto-Lei. 4.657/42), é inevitável reconhecer que a prisão é o ato de polícia máximo, razão pela qual este raciocínio é inválido por legitimar uma verdadeira equiparação das guardas municipais às polícias, conferindo a elas um poder de polícia completo. Mais. Não se pode desconsiderar a interpretação sistemática do feixe de atribuições instituído pelo constituinte no art. 144, o qual confere às polícias militares a função da patrulhamento ostensivo. De forma que as diligências preventivas, com as exceções expressas da constituição para a polícia federal (tráfico, contrabando e descaminho, policiamento marítimo, portuário e de fronteiras) e as guardas municipais (bens, serviços e instalações municipais), cabem tão somente às PMs. Vale ressaltar que é exatamente nesse sentido o entendimento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade contra Lei Municipal n. 13.866/06 que fixava, dentre as atribuições da guarda municipal da capital, "exercer, no âmbito do Município de São Paulo, o policiamento preventivo e comunitário, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos", assim entendeu o órgão máximo do tribunal. Confira-se a ementa:

Ação Direta de Inconstitucionalidade – art. 1º, inc. I da Lei n. 13.866/2004, do Município de São Paulo, que fixa atribuições da Guarda Civil Metropolitana – Art. 147 da Constituição Estadual – Proteção dos bens, serviços e instalações municipais – Matéria debatida é atinente à segurança pública – Preservação da ordem pública – Competência das polícias, no âmbito do Estado – Atividade que não pode ser exercida pelas guardas municipais – Extrapolação dos limites constitucionais – Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo. (ADI nº 154.743-0/0-00, Rel. Des. Mauricio Ferreira Leite, j. 10/12/2008).

Trata-se, como se percebe, de entendimento consolidado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei 5.626, de 16 de abril de 2018, do Município de Valinhos, que assegurou à Guarda Municipal a identificação como 'Polícia Municipal de Valinhos' - Alegação do Prefeito, autor da ação, de usurpação da competência privativa do Poder Executivo para disciplinar matéria sobre a organização dos serviços públicos municipais, violando a separação dos poderes - VÍCIO DE INICIATIVA - Projeto apresentado por parlamentar direcionado à nova designação da Guarda Municipal - Matéria claramente de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme interpretação dos artigos 5º, 24, § 2º, item 4, 47, incisos II, XI, XIV e XIX, alínea 'a', da Constituição Bandeirante, aplicável aos Municípios por força do seu artigo 144 - Incidência, ainda, do preceito do artigo 147 da Carta Bandeirante, que reproduz o texto do artigo 144, § 8º, da CF/88, que estabelece que a guarda municipal é força de natureza civil destinada à proteção de bens, serviços e patrimônio municipal, sem se imiscuir na Segurança Pública preventiva e ostensiva de atribuição dos Estados e União - Inconstitucionalidade das guardas municipais adotarem a identificação de 'polícia', e ainda mais como 'militar', dada sua natureza civil - Não violação, por outro lado, dos preceitos orçamentários, segundo Tema 917, em repercussão Geral, no S.T.F. - Ação julgada procedente. TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2286983-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020.

É essa também a lição da doutrina constitucionalista.

José Afonso da Silva (Comentário Contextual à Constituição, 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638/639) assevera que:

Os constituintes recusaram várias propostas no sentido de instituir alguma forma de Polícia Municipal. Com isso, os Municípios não ficaram com qualquer responsabilidade específica pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que, sendo entidades estatais, não podem eximir-se de ajudar os Estados no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança, e menos ainda de polícia judiciária. A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir Guardas Municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí, certamente, está uma área que é de segurança: assegurar a incolumidade do patrimônio municipal, que envolve bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens patrimoniais, mas não é de polícia ostensiva, que é função da Polícia Militar. Por certo que não lhe cabe qualquer atividade de polícia judiciária e de apuração de infrações penais, que a Constituição atribui com exclusividade à Polícia Civil (art. 144, §4º), sem possibilidade de delegação às Guardas Municipais.

Pinto Ferreira (Comentários à Constituição Brasileira, v. 5, p. 246) observa que:

A Constituição de 1988 atribuiu às Guardas Municipais a tarefa de proteção aos bens, serviços e instalações do Município, conforme dispuser a lei (art. 144, § 8º), não as fazendo auxiliares da Polícia Militar nem lhes conferindo função repressiva dos crimes.

Lesley Gasparini Leite e Diógenes Gasparini (Lesley Gasparini Leite e Diógenes Gasparini, Guarda Municipal - Criação e Implantação - Constituição Federal - Constituição Estadual - Lei Orgânica do Município, in Boletim de Direito Municipal, ano IV, nº 3, pág. 203) também destacam que às guardas municipais "não lhes cabem, portanto, os serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de Polícia Judiciária e de apuração das infrações penais. Aliás, essas competências foram essencialmente atribuídas à Polícia Militar e à Polícia Civil".

Não diverge a melhor doutrina processual penal.

Gustavo Badaró (Processo Penal, 3ª ed, 2015, p. 496), professor titular de Direito Processual Penal da USP, afirma que:

(...) há consenso no sentido de que os guardas municipais não podem realizar buscas pessoais. Por expressa previsão constitucional, cabem-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo atribuída nenhuma função de prevenção ou investigação de crimes.

O Desembargador Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal comentado, 2017), por sua vez, ensina:

Agentes autorizados a realizar busca pessoal: são os que possuem a função constitucional de garantir a segurança pública, preservando a ordem e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como investigar ou impedir a prática de crimes: polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares (art. 144, CF). Não possuem tal função os agentes das guardas municipais, logo, não estão autorizados a fazer busca pessoal. Naturalmente, se um flagrante ocorrer, podem prender e apreender pessoa e coisa objeto de crime, como seria permitido a qualquer do povo que o fizesse, apresentando o infrator à autoridade policial competente.

Enfim, qualquer que seja o caminho argumentativo, não podem os membros das guardas municipais proceder à qualquer diligência invasiva.

Ora, se mesmo quando diante de flagrante delito, cabe a eles somente encaminhar o autor da infração ao delegado de polícia, por qual razão poderiam proceder à busca pessoal se sequer sabiam se a pessoa acusada encontrava-se nessa situação? Se tinham fundadas suspeitas de cometimento de crime grave (equiparado a hediondo) por parte do agente, deveriam ter, em respeito ao texto constitucional, comunicado à Polícia Militar e/ou Civil para que tomassem as medidas necessárias.

A disciplina constitucional (art. 5º, inciso LVI) é inequívoca:

são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos

Como a diligência policial foi ilícita, ela não pode ser considerada uma causa justa para fundamentar uma acusação criminal.

Como a prova da imputação do tráfico não possui outra fonte independente (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal), é forçoso reconhecer não há condições para o exercício da ação por falta de justa causa.

Ante o exposto, REJEITO a denúncia oferecida contra Wanderson Antonio Gonçalves, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

De forma sucinta, o flagrante foi declarado ilegal porque a abordagem feita pelos agentes públicos baseou-se tão somente em denúncia anônima.

Após, a instrução e oitiva dos guardas municipais, o acerto desse entendimento do STJ revelou-se particularmente importante. Isso porque, questionado pela defesa a respeito do trajeto feitos pelos guardas municipais (entre o Jardim Anésia e a Vidro Porto), uma vez que a Vidro Porto não se encontra no caminho entre o Jardim Anésia e o Centro, o guarda municipal afirmou que a denúncia era relativa ao Centro ou à Vila Maria. Ouvido na sequência, o outro guarda afirmou que a denúncia era relativa ao Centro.

Isso denota a fragilidade do padrão utilizado pelos guardas municipais para realizar a busca pessoal. A verdade é que, acolher este tipo de justificação, é tornar a diligência invasiva insuscetível de controle (como saberemos realmente se a denúncia era relativa exclusivamente ao Centro ou se englobava a Vila Maria se ea foi anônima?) e, portanto, permitida ao estado em quaisquer hipóteses, o que não se coaduna com a existência da garantia fundamental dos direitos à intimidade e à livre locomoção (necessidade de regulação do chamado stop and frisk).

Na decisão que rejeitou a denúncia foi acrescido que os guardas municipais agiram fora do desenho constitucional e legal conferido à corporação, vez que não atuavam

para a proteção dos bens, serviços e instalações municipais; além disso, não estavam diante de uma situação de flagrante delito e não tinham poderes para proceder à busca pessoal (diligência que não pode ser feita por qualquer do povo). Aliás, foi como a própria 13ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou recentemente (26/05/2022) na Apelação Criminal 1500971-90.2021.8.26.0545, relatada pelo Desembargador Marcelo Semer (grifos conforme original, destaques nossos com fundo amarelo):

Observa-se, pelo conjunto probatório, que os Guardas Civis Municipais se dirigiram ao conjunto habitacional "Caetetuba II" conhecido popularmente como "prédios coloridos", com informações descritas por eles como advindas dos "meios policiais" de que se tratava de local onde ocorria tráfico de drogas, para fazer uma incursão com o objetivo de cessar a traficância naquela localidade. Então, os guardas entraram no condomínio pelos fundos do bloco 2, e abordaram o réu no térreo deste bloco.

Trata-se de evidente usurpação de função da Polícia Judiciária ou Repressiva por parte dos Guardas Municipais. É fato incontroverso que qualquer do povo pode executar uma prisão em flagrante delito, incluindo os Guardas Municipais. Entretanto, o que ocorreu no caso não foi um mero flagrante, mas uma explícita operação de repressão ao tráfico de drogas, incluindo a entrada nas dependências de conjunto habitacional sem prévio mandado, a partir de informações não registradas, em atuação que maculou todo o processo.

A lei 13.022/14 que disciplina o Estatuto Geral das Guardas Municipais instituiu normas gerais para tal órgão público. Nos termos do art. 144, §8º, Constituição Federal, as Guardas Municipais sempre possuíram competência vinculada à proteção patrimonial municipal, sendo que esta vocação constitucional consta no art. 4º da Lei 13.022/14: "é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município". Esta lei também estabeleceu, no rol de competências específicas das Guardas Municipais (art. 5º):

V - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal, deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

As Guardas Municipais podem, portanto, atuar em colaboração com os demais órgãos de segurança pública, desde que no exercício de suas competências, jamais atuando isoladamente em diligências investigativas típicas da Polícia Judiciária.

No caso, os guardas deliberaram pela entrada irregular em conjunto habitacional com o objetivo de atuação repressiva contra o tráfico de drogas a partir de inteligência informal, não se verificando a situação de flagrante delito do artigo 301 do Código de Processo Penal. De tal forma, a ilegalidade de tal ação infirmou todas as provas dela advinda.

(...)

Portanto, ausente prévia e visível situação de flagrante delito eu permitisse a entrada da Guarda Civil Municipal sem autorização no conjunto habitacional - dado que não houve visualização por parte dos guardas de crime sendo cometido durante sua atuação ordinária, e sim verdadeira diligência repressiva a busca e apreensão pessoal sobre o réu e demais provas dela derivadas devem ser consideradas nulas, em decorrência da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, CPP).

Segundo explica a doutrina, "a posição mais razoável e que melhor garante os direitos individuais é aquela que reconhece que a ilicitude da obtenção da prova se transmite às provas derivadas, que, igualmente, devem ser consideradas inadmissíveis no processo. Não se pode admitir a utilização da prova ilícita por derivação, sob pena de burlar a própria inadmissibilidade da prova ilícita" (in Processo penal[livro eletrônico] -- 6. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020). (...)

No mais, quanto ao mérito, reconhecida a ilicitude do meio de obtenção de prova (busca e apreensão), bem como das provas dela derivadas, de rigor a absolvição do réu com relação ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, diante da fragilidade probatória a embasar um decreto condenatório.

Isso porque, inexistem, in casu, quaisquer indícios a apontar o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, não sendo suficiente, para tanto, meras denúncias anônimas ou suspeitas policiais.

Segundo explica a doutrina, "os fundamentos absolutórios da sentença penal decorrem da dimensão de regra probatória da presunção de inocência (CR, art. 5º, LVII) e do instituto do ônus da prova, em seu aspecto objetivo. Este consiste em regra de valoração do resultado da prova, que impõe a absolvição quando houver dúvida judicial quanto à veracidade dos enunciados fáticos contidos na denúncia ou queixa-crime (in dubio pro reo)" (in Código de processo penal comentado [livro eletrônico] -- coordenação Antonio Magalhães Gomes Filho, Alberto Zacharias Toron, Gustavo Henrique Badaró -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Dessa forma, é o caso de reconhecer a nulidade da busca e apreensão realizada sobre o réu, bem como da prova dela derivada, o que leva à absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso defensivo, para reconhecer a ilicitude das provas decorrentes da incursão repressiva operada por Guardas Civis Municipais, e, no mérito, absolver o réu da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, L. 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Os guardas municipais não agiram para a proteção de bens, serviços e instalações municipais, mas para apurar denúncia anônima de tráfico, em nítida atuação de investigação, ou seja, de "apuração de infração penal), a qual cabe tão somente à Polícia Civil (§5º do art. 144 da Constituição) e à Polícia Federal (§1º do art. 144 da Constituição).

A atividade de segurança pública exercida pelos guardas municipais deve estar ligada à proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios. Não cabe às GCMs atuar em substituição aos órgãos da segurança pública fora dos parâmetros constitucionais. Podem, no máximo, nos termos da Lei 13.675/2018, atuar em cooperação com os órgãos de segurança pública (estes delimitados taxativamente no art. 144 da Constituição), mas, como ressalva a própria lei (art. 9º), "nos limites de suas competências".

Portanto, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, as provas colhidas pela acusação foram obtidas por meios ilícitos, as quais são inadmissíveis nos termos do inciso LVI do art. 5º da Constituição.

Ressalto também não ser possível se valer das declarações da ex-companheira; primeiro ela não foi sequer arrolada para ser ouvida em juízo; depois porque, naqueles autos, incriminava a pessoa imputada com outra acusação, colocando sob dúvida suas intenções.

Em relação ao estado de liberdade da pessoa imputada tendo a questão sido analisada pelas instâncias superiores a partir de circunstâncias de fato e de direito próximas àquelas analisadas nesta sentença, deixo de me manifestar, devendo eventuais pedidos ser direcionados a tais instâncias.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório para ABSOLVER WANDERSON

ANTONIO GONCALVES das acusações a ele imputadas na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.
Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.
Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.
Com o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações de praxe.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 12 de julho de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA